

0000697-34.2013.8.26.0691

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Quadrilha ou Bando

Magistrado: GILVANA MASTRANDÉA DE SOUZA

Comarca: Buri

Foro: Foro de Buri

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... O vínculo associativo que une os membros de uma associação para o tráfico de drogas não é suficiente para torná-los igualmente responsáveis por todos os crimes de tráfico que o bando eventualmente praticar - Análise da participação de cada réu em cada um dos crimes que lhe foi imputado - Necessidade - Vedação da responsabilidade penal objetiva. 2. Associação para o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Buri

Foro de Buri - Vara Única

Rua Carlos Alberto Pereira Jr, 549, Buri - SP - cep 18290-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0000697-34.2013.8.26.0691 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000697-34.2013.8.26.0691

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Quadrilha ou Bando

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSUÉ LUIZ FERREIRA e outros

Julgamento conjunto

autos 0000697-34.2013.826.0691 e 0000750-73.2017.826.0691

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GILVANA MASTRANDÉA DE SOUZA

Vistos.

I - RELATÓRIO

MARCELO NASCIMENTO da SILVA, EFERSON JOSÉ SEVERINO da SILVA, EMERSON MESSIAS SEVERINO da SILVA, FÁBIO CRUZ de ARAÚJO, JOSUÉ LUÍS FERREIRA, RÔMULO JACQUES FRANCO e LEANDRO PAULA da SILVA, foram denunciados e estão sendo processados pela prática dos crimes previstos no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal (antes da alteração promulgada pela Lei n. 12.850/13), no artigo 16, caput e artigo 15, caput, ambos da Lei n. 10.826/03, e no artigo 155 §§ 1º e 4º, inciso IV do Código Penal.

Isto porque, segundo a denúncia:

"Consta dos autos de inquérito policial que, em data e local incertos, MARCELO NASCIMENTO da SILVA, EFERSON JOSÉ SEVERINO da SILVA, EMERSON MESSIAS SEVERINO da SILVA, FÁBIO CRUZ de ARAÚJO, JOSUÉ LUÍS FERREIRA, RÔMULO JACQUES FRANCO e LEANDRO PAULA da SILVA, qualificados nos autos, associaram-se, em quadrilha armada, para o fim específico de cometer crimes.

Conforme apurado, os denunciados, em companhia de outras pessoas não identificadas, associaram-se, em quadrilha, de maneira estável e com divisão específica de tarefas, para o fim de cometer crimes de furto a bancos, munindo-se, para tanto, de armas de fogo e explosivos. Consta, ainda, que, na madrugada de 11 de maio de 2013, por volta das 2h50, na Praça Nove de Julho, no Município de Buri, os réus

qualificados nos autos, portavam armas de fogo, tipo fuzil e munições calibres 5,56mm, 7,62x39mm, e 9mm, de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal, conforme boletim de ocorrência a fls. 4/7 e laudos periciais a fls. 129/143 e 253/261.

Os denunciados, no dia dos fatos, portavam armas de fogo, na via pública, três fuzis, ao menos, além das respectivas munições calibres 5,56mm, 7,62x39mm, e 9mm, em número indeterminado, de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Consta, também, que, nas mesmas circunstâncias, no Município de Buri, os réus, qualificados nos autos, durante o repouso noturno, com destruição de obstáculo, mediante concurso, subtraíram, para si, quantia não especificada, em dinheiro, do Banco do Brasil, consoante boletim de ocorrência a fls. 4/7, imagens a fls. 60/62, relatórios a fls. 77/80, 100/101, 129/143, 154/179 e laudos periciais a fls. 129/143 e 253/261.

No dia dos fatos, os denunciados, associados com outros comparsas não identificados, rumaram ao Banco do Brasil, com o propósito de subtrair o dinheiro dos caixas eletrônicos.

Para tanto, dois dos denunciados entraram no banco, encapuzados, munidos de arma de fogo, colocaram os explosivos nos caixas eletrônicos, detonaram a carga e, feito isso, subtraíram grande quantia em dinheiro.

Nesse ínterim, os demais denunciados, em conjunto com outros criminosos não identificados, faziam a segurança armada, no lado externo da agência bancária, na via pública, para garantir o sucesso da conduta criminosa.

Consta, ademais, que, nas mesmas circunstâncias, no Município de Buri, os réus, qualificados nos autos, dispararam arma de fogo, na via pública, conforme boletim de ocorrência a fls. 4/7 e laudos periciais a fls. 129/143 e 253/261.

Os denunciados, no dia mencionado, efetuaram diversos disparos de arma de fogo, utilizando-se de, pelo menos três fuzis, calibres 5,56mm, 7,62x39mm, e 9mm, na via pública, entre a Praça Nove de Julho e a agência do Banco do Brasil."

A denúncia foi recebida em 22 de setembro de 2015 (fl. 290, dos autos 697-34.2013)

Os acusados foram devidamente citados: Marcelo Nascimento Da Silva (fls. 318), Eferson José Severino da Silva (fls. 323), Emerson Messias Severino da Silva (fls. 408), Josué Luis Ferreira (fls. 326), Rômulo Jacques Franco (fls. 335), Fábio Cruz de Araújo (fls. 331).

Apresentaram defesa prévia através de advogado dativo (fls. 442/443 dos autos 697-34.2013).

O réu Fábio Cruz de Araújo constituiu advogado (fls. 541, dos autos 697-34.2013). Foi declarada extinção da punibilidade dos averiguados Roger Alexandro Medger Filho e Lucas Camilo da Silva por sentença às fls. 430/431 em virtude do falecimento deles (certidões de óbito fls. 213 e 407). Na mesma ocasião foi desmembrado o processo quanto ao réu Leandro Paulo da Silva pois não havia sido localizado para citação (fls. 430), distribuição nº 0000750-73.2017.826.0691.

Em audiência de instrução realizada, foram inquiridas 03 testemunhas arroladas pelo Ministério Público e arroladas pela Defesa.

Após diversas tentativas de localizar a testemunha Rita de Cássia Lima dos Santos (fls. 91/92), o Ministério Público desistiu da oitiva da mesma (fls. 787), e foi declarada encerrada a instrução processual (fls. 798).

Os réus Josué Luiz Ferreira e Fabio Cruz De Araujo, e a informante Raquel de Jesus Batista, foram ouvidos (fls. 539/540).

Em relação ao réu Marcelo Nascimento da Silva, foi declarada sua revelia em 06 de julho de 2018, fls. 544, uma vez que o réu após ser citado evadiu-se da penitenciária em que estava recolhido (fls. 451).

Os réus Eferson José Severino da Silva, Emerson Messias Severino da Silva e Rômulo Jacques Franco foram interrogados através de carta precatória, respectivamente a fls. 593/622, 676/684 e 567/592.

As testemunhas de acusação Carlos Eduardo Santos de Arruda e Luiz Afonso Vieira também foram ouvidos através de carta precatória a fls. 686/723.

Nos autos desmembrados 0000750-73.2017.826.0691 (réu Leandro Paulo da Silva), sobreveio regular citação (fls. 487) e o réu apresentou defesa prévia por advogado

constituído (fls. 492/494). O feito teve regular instrução, com oitiva de testemunhas de acusação e defesa e foi realizado interrogatório. Ambas as partes desistiram da oitiva da testemunha Rita de Cássia (fls. 777).

Concomitantemente, sobreveio encerramento da instrução processual em ambos os processos, tendo sido determinada a vinda à conclusão para julgamento em conjunto. Em sede de alegações finais por memoriais, o Ministério Público pleiteou a condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência probatória.

É o relatório.

Fundamento e decido.

II – PRELIMINARES

A arguição de cerceamento de defesa ventilado pela defesa dos acusados Eferson, Emerson, Josué, Marcelo e Rômulo (fls. 948/951 dos autos 0000697-34.2013) deve ser rechaçada. Argumenta a Defesa técnica que os réus foram tolhidos da oportunidade de oitiva da testemunha Rita de Cássia Lima. Sucede que o genérico argumento não merece acolhimento pelos fundamentos expostos às fls. 798. Além disso, a despeito da arguição de cerceamento de defesa, a parte não demonstrou a viabilidade da oitiva da testemunha (cujo paradeiro é desconhecido) e não requereu quaisquer diligências para sua localização. Dessa forma, não há como reconhecer eventual prejuízo a ensejar a decretação de nulidade processual.

Quanto ao mais, o processo se instaurou e se desenvolveu regularmente, não havendo nulidades outras a serem declaradas.

Com efeito, o Juízo é competente, respeitou-se o direito de defesa e garantiu-se o contraditório do acusado.

Ainda, estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, inexistindo alegações das partes de outros vícios processuais.

Assim, verificada a regularidade do processo, passa-se à análise de mérito.

III – MÉRITO

Finalizada a instrução penal, verifica-se que a prova dos autos é frágil para apontar a responsabilidade penal dos réus.

A materialidade do crime de furto e de disparo de arma de fogo restou comprovada através dos seguintes elementos de prova colhidos no Inquérito Policial: boletim de ocorrência (fls. 04/07 dos autos 697-34.2013), auto de apreensão (fls. 20/21), laudo de confronto balístico a fls. 129/143, laudos periciais do local (fls. 253/261), laudo dos detonadores de dinamite (fls. 263/264), laudo projéteis de arma de fogo (fls. 100/101); imagens da câmera de segurança do estabelecimento (fls. 60/62), laudo da bomba no local do crime (fls. 147/152), relação de valores subtraídos (fls. 314), laudo do gorro recolhido no local do crime (fls. 275/276), além da prova oral colhida nas duas fases da persecução penal. O crime de porte de arma de fogo de uso restrito é classificado pela doutrina como crime de mera conduta e de perigo abstrato, ao passo que o crime de quadrilha ou bando é classificado como formal, ou de consumação antecipada. Com isso, tem-se que a consumação desses crimes é concomitante à conduta, de modo que se mostra prescindível a análise do resultado (materialidade), ou mesmo de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, para configuração da infração penal em comento. Anoto que todas as peças processuais mencionadas constam nos autos desmembrados (750-73.2017).

No que tange à autoria, por sua vez, encerrada a instrução processual, permanecem dúvidas, que beneficiam os acusados.

Vejamos:

De início, tem-se que todos os acusados negaram as acusações.

O acusado Rômulo, em juízo, negou todas as acusações, disse que sequer sabe onde fica a cidade de Buri. Declarou que conhece EFERSON e EMERSON, porque tinha uma loja de som e eles sempre estavam lá; moravam perto. Não teve contato com armamento algum. Não teve escuta telefônica e a Polícia não foi em sua casa, foi simplesmente preso sem saber o motivo; não apresentaram arma, nada. É primário. É gesseiro, casado e tem filho. Possui segundo grau completo.

O acusado Fábio, em juízo, disse que trabalha de motorista há 20 (vinte) anos, não possui a carteira assinada atualmente, é casado e possui três filhos. Já foi

processado anteriormente, estava em regime aberto. A respeito dos fatos, declarou que nunca praticou roubo algum, sempre trabalhou. Nunca foi até Buri. Não conhecia ninguém. Conheceu JOSUÉ na cadeia. E os outros conheceu em um transfer em Itapetininga, depois de nove meses. Chegaram até ele, porque conversou com ROGER uma vez no telefone; uma pessoa passou o seu telefone para ROGER, falando que ele tinha um carro financiado para vender; acredita que o telefone do ROGER estava no grampeado e acha que grampearam o seu telefone também. Roger não chegou a ver o carro. No outro processo, foi condenado junto com eles, porque não tinha dinheiro para pagar advogado e a esposa fez uma cirurgia e não levou os papéis que precisava. Disse que olharam em sua casa e não acharam nada, mas foi levado preso. Não chegou a conhecer ROGER. Nunca pegou em arma. Não lembra o número de seu celular. Parou de usar o telefone em 2014, quando foram até a sua casa e apreenderam o celular e o Nextel.

O acusado Josué, em juízo, disse que trabalhava de balconista com o seu pai, é casado e tem filhos. Não é usuário de drogas, mas bebe todos os dias. Já foi processado criminalmente por roubo. Não sabe exatamente por que está preso. Não conhece os outros acusados. Nunca esteve em Buri. Nunca participou de nenhum furto de caixa eletrônico. Quando ficou preso com FÁBIO, ele disse que não tinha nada a ver com os crimes e que acabou caindo na escuta quando estava tentando vender um carro para uma pessoa. Ficou preso com FÁBIO três anos; todos comentavam que ele não tinha nada a ver, que FÁBIO era um "cara" trabalhador. Está preso por Sarapuí; FÁBIO também está preso por lá. No processo de Sarapuí já tem condenação.

O acusado Eferson, em juízo disse que não tem nada a ver com os crimes. Foi preso em 2014 devido a uma chácara que está no nome de seu irmão, onde foram apreendidos vários artefatos. A vizinha disse que a chácara estava arrombada e realmente estava; a polícia tinha achado algumas coisas lá. Tentaram conversar com o delegado de Paranapanema, mas ele não quis ouvir. Passado um ano, a Polícia invadiu a sua casa e prendeu ele e seu irmão, acusado desses fatos e outros. Até então não tinha nada contra eles. O delegado de Itapetininga mandou as suas digitais para onde tinha investigação de roubo de caixa eletrônica. O seu irmão é EMERSON. Disse que não para de chegar processo, está respondendo a vários. Conhece o acusado EMERSON (é seu irmão), JOSUÉ (trabalhava com EMERSON), RÔMULO (tinha uma loja perto da sua loja) e LEANDRO (é pedreiro, fez a reforma da chácara). A chácara fica em Paranapanema; não sabe dizer se fica perto de Buri. Não tinha nenhum outro processo anterior.

O acusado Emerson, em juízo, disse que nem passou em Buri. Conhece EFERSON (é seu irmão) e JOSUÉ (era seu funcionário). Mora em Votorantim. Tem uma chácara no município de Paranapanema, que foi arrombada, lá tinha o monte de munições e armas e que assim a Polícia chegou até ele. Não eram suas as munições e armas. A chácara estava arrombada. Foi preso em 2014 em razão de fatos relacionados ao aqui investigado; eles falaram que ele estava envolvido nos furtos de várias cidades. Disse que em sua casa, em Votorantim, tinha circuito de câmara, o qual foi destruído pela Polícia; era a única prova que tinha que estava em Votorantim no dia dos fatos. Na época dos fatos, tinha um bar. Por causa do horário, não estava no bar, estava em sua casa, por isso não conseguiu Testemunhas.

O acusado Leandro, interrogado nos autos n. 0000750-73.2017.8.26.0691 disse que era motorista, possui sete filhos maiores, não é usuário de drogas, não respondeu nenhum processo. Declarou que não tem o que falar, porque não tem conhecimento dos fatos. Ele soube que seu filho Lucas estava na casa da namorada; mas depois EFERSON disse que estaria em outro lugar, o seguiu então; quando chegou pra frente da entrada de Buri, encostou e viu Lucas sendo carregado por Silvio, vulgo Biba, e EFERSON, do mato; perguntou o que houve, e disseram que Lucas foi alvejado com um tiro; levou o filho para o hospital; ele faleceu e foi sepultado no dia primeiro; no dia 04 (quatro) levaram o dinheiro (quatorze mil), isto é, a parte de Lucas, para ele; disse que iria entregar o dinheiro para o delegado, mas não deu tempo. Deu o depoimento na delegacia entregando EFERSON, RÔMULO, EMERSON e Silvio. Ficou preso por 64 dias. Disse que foi EFERSON que fez a armadilha para ele. Disse que o seu vizinho Francisco relatou que um Corsa estava lá e dava cobertura para o pessoal. Disse, ainda, que um policial, que trabalhava para EFERSON, ajudou armar

para ele. Disse que nunca cometeu nenhum crime. Não tem problema com homônimo. Tentou ligar para o delegado Vitor, mas não conseguiu; não deu tempo de entregar o dinheiro para a Polícia. Disse que acha que está preso por esse fato, desconhece outros fatos e processos. Disse que nunca praticou crime algum. Disse que o filho tinha envolvimento com a quadrilha.

Acrescente-se que é dos autos que Marcelo Nascimento da Silva não foi interrogado em juízo em razão da decretação de sua revelia. Em fase policial, o acusado negou os fatos a ele atribuídos (fls. 221).

Em relação às provas produzidas, tem-se o relato das duas testemunhas de acusação ouvidas em juízo em ambos os processos, conforme se expõe a seguir.

Luis Afonso Vieira, policial civil, declarou que atuou em investigação relativa à furto a caixas eletrônicos mediante explosão ocorrido na cidade de Sarapuí.

Esclareceu que essa cidade pertence à região pela qual a Delegacia em que está lotado é responsável. A investigação iniciou em janeiro de 2013. Afirmou que em momento futuro, após realização de laudo pericial de confronto balístico que comparou cartuchos encontrados nas cenas de crimes de suas investigações com cartuchos encontrados após o furto praticado em Buri, chegou-se à conclusão de que uma mesma arma efetuou disparos nas diferentes cidades. Em razão disso, foi autorizado o compartilhamento de provas, razão pela qual as informações foram remetidas para Buri. Contou que, em relação ao crime praticado em Sarapuí, a investigação iniciou a partir de interceptação de uma linha telefônica que foi utilizada para afastar a guarnição da polícia militar do local dos fatos. Com as interceptações telefônicas, chegaram à conclusão de que Marcelo Nascimento da Silva efetuava o cadastro de linhas telefônicas para o grupo, inclusive de linhas que foram utilizadas no momento do crime praticado em Sarapuí. Após, a investigação se aprofundou com a interceptação de outras linhas e IMEIs. Contou que um dos telefones interceptados foi utilizado em crime bastante semelhante praticado na cidade de Elias Fausto, que ocorreu cerca de dois meses após o crime de Sarapuí. Depois desse crime, com o prosseguimento e aprofundamento das investigações, o grupo foi identificado e houve novo compartilhamento de provas com a cidade de Paranapanema, com a posterior identificação de todos os integrantes da quadrilha. Aduziu que, com a soma dos elementos reunidos na investigação iniciada após o furto a caixa eletrônico praticado em Sarapuí (aí incluído o laudo de confronto balístico), com as informações reunidas pela autoridade policial da comarca de Paranapanema, chegou-se à conclusão de que todos os réus deste processo estavam envolvidas na explosão.

Carlos Eduardo Santos de Arruda, policial civil, declarou que a investigação iniciou após uma explosão de caixa eletrônico em Sarapuí. Afirmou que seu colega Luis Afonso foi quem cuidou de toda parte de interceptação e levantamento de linhas telefônicas. Afirmou, sobre sua atuação nas investigações, que monitorou apenas um integrante da quadrilha, o ROGER, que é falecido. Contou que recebeu informações relacionadas aos demais investigados por intermédio de seu colega Luis Afonso. A seguir, em linhas gerais, ratificou o depoimento de Luis Afonso, descrevendo a investigação de maneira harmônica e coerente com os relatos de seu colega. Tais relatos reforçam alguns elementos de prova coligidos durante a fase investigativa. Contudo, a ausência de outras provas torna o conjunto probatório frágil e insuficiente para, em juízo de certeza, concluir pela autoria de quaisquer dos crimes imputados aos réus, conforme se passa a expor.

De início, tem-se que a denúncia imputou ao réus a prática do crime de quadrilha em "data e local incertos". A ausência de limitação do tempo da conduta, por si só, prejudica em algum grau a análise do mérito e, quando menos, impõe algum embaraço ao exercício da ampla defesa e do efetivo contraditório.

Isso porque, da forma como descrito na peça acusatória, não é possível distinguir a imputação feita aos mesmos réus nos autos nº 0002697-12.2013.826.0269, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapetininga. Conforme se extrai da sentença proferida nos autos 0002697-12.2013, disponível para consulta no e-saj, todos os réus deste feito foram denunciados e condenados pela prática do crime tipificado no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, porque se associaram para o fim de cometer um número indeterminado de crimes de furtos mediante artefatos

explosivos em caixas eletrônicos em data anterior a 30 de janeiro de 2013. Acrescente-se que nos autos 0001859-51.2013.826.0372, que tramitou perante a Comarca de Monte Mor, alguns dos réus desta ação foram também condenados pela prática do crime tipificado no art. 288, do Código Penal, havendo menção, no acórdão que julgou o recurso de apelação, que a associação criminosa persistiu no interregno entre janeiro e outubro de 2013, período que engloba os fatos descritos nesta ação penal.

Aliado a isso, não se pode argumentar que o crime de quadrilha se consumou nesta comarca de Buri quando do furto mediante explosão a caixa eletrônico praticado aos 13/05/2013, porque, como se verá adiante, o conjunto probatório não autoriza a conclusão de que os acusados foram os autores do delito, sendo a absolvição por insuficiência de provas a medida necessária.

Pontue-se que a insuficiência de provas, no que toca especificamente ao crime de quadrilha, revela-se na circunstância de que inexistem nos autos elementos que demonstrem que os réus estiveram nesta cidade de Buri em algum momento e que, entre si, tivessem planejado e executado o crime de furto a eles imputado nesta ação. A prova nesse sentido é circunstancial e, mesmo considerados todos os elementos em conjunto, impossível extrair-se o juízo de certeza necessário para o decreto condenatório.

A esse respeito, anoto que foram indeferidas duas representações da autoridade policial local para quebra de sigilo telefônico (fls. 64 e fls. 69), de modo que os elementos coligidos na fase investigativa basicamente se resumem a informações obtidas por investigações paralelas, de crimes cometidos nas cidades adjacentes, especialmente Sarapuí e Paranapanema. E, dentre esses elementos, não há nenhum capaz de individualizar a conduta dos acusados quando da alegada atuação da quadrilha nesta cidade de Buri.

Ainda nesse sentido, tem-se que os relatórios acostados no inquérito policial e o depoimento dos policiais civis são aptos para atestar a existência do crime de quadrilha e a autoria dos demais crimes praticados em outras localidades. Contudo, tais elementos são insuficientes para a comprovação da autoria dos crimes descritos nesta ação penal.

No que concerne ao crime de furto, de igual sorte, a prova circunstancial coligida não é suficiente para firmar juízo de certeza sobre a autoria.

É dos autos que, durante a fase investigativa, apurou-se que (i) o modus operandi do crime (notadamente o uso de explosivos e de armas de fogo e a prévia comunicação falsa para forçar deslocamento da guarnição da Polícia Militar para local distante) é bastante semelhante daquele observado em outras localidades, em especial Sarapuí; (ii) o crime foi praticado em concurso de pessoas; (iii) o laudo de confronto balístico demonstra que uma mesma arma foi utilizada em diferentes cidades em que houve atuação da quadrilha; (iv) uma testemunha reconheceu, por imagem de câmeras de segurança, dois dos acusados.

A esse respeito, oportuno destacar que é vedado ao juiz fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação (art. 155, CPP). Depois, anote-se que o reconhecimento em sede policial (fls. 93 dos autos 697-34.2013), sem a confirmação em juízo, revela-se como frágil elemento, que não permite a conclusão da autoria delitiva, sobretudo porque, do que consta, os indivíduos permaneceram encapuzados (com toucas "ninja") durante a ação criminosa e utilizavam calça jeans, casaco, tênis e luvas (ou seja, sequer é possível ter certeza sobre a cor da pele dos sujeitos), de modo que o reconhecimento, feito por imagem, ocorreu por circunstâncias genéricas, como aspecto físico, modos de vestir e trejeitos. Nesse sentido, as imagens exibidas às fls. 60/62 (dos autos 697-34.2013) demonstram a fragilidade desse elemento de prova e reforçam a necessidade de sua confirmação em juízo. Sem que isso tenha ocorrido, não há outra alternativa que não reconhecer que tal elemento se consubstancia apenas em indício de autoria. Assim, não existindo elementos probatórios seguros, tem-se por inafastável o princípio do in dubio pro reo. Nesse sentido, destaca-se precedente similar, em que se reconheceu a incidência do princípio aludido em caso em que o reconhecimento realizado em fase policial não teve confirmação em juízo:

"APELAÇÃO. Latrocínio e roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de

fogo. Recursos defensivos. Preliminares. Pedido de realização de exame pericial. Indeferimento do pleito d. juízo a quo de forma fundamentada. Nulidade por cerceamento de defesa em face da ausência de solicitação das imagens das câmeras de segurança da via pública. Não ocorrência. Pedido que não foi realizado no momento oportuno. Pretensão de afastamento da revelia. Ausência de comparecimento do acusado Rafael aos atos do processo que gerou unicamente o efeito previsto no artigo 367, do Código de Processo Penal. Inobservância do artigo 226, do CPP. Ausência de formalidade que não anula o reconhecimento do acusado. Preliminares afastadas. Mérito. Absolvição por insuficiência de provas. Admissibilidade com relação aos acusados Rafael e Jhonatan. Ausência de elementos probatórios seguros para a condenação. Reconhecimento realizado na fase policial sem confirmação em juízo. Existência de meros indícios de autoria. Aplicação do princípio do in dubio pro reo. Conjunto probatório harmônico e coeso que comprova a materialidade e autoria do delito quanto ao acusado Renan. Condenação mantida. Dosimetria da pena e regime para o seu cumprimento que não comportam reparos. Negado provimento ao recurso interposto em favor de Renan e apelos defensivos interpostos em favor de Rafael e Jhonatan providos para absolvê-los, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP". (TJSP; Apelação Criminal 0006069-83.2015.8.26.0176; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Embu das Artes - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 06/12/2018; Data de Registro: 06/12/2018) Ainda em relação ao reconhecimento fotográfico, no julgamento do HC 652.284 o ministro Reynaldo Soares da Fonseca registrou que "o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível (...) "no caso de uma ou de ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração independente e idônea do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial".

Quanto ao mais, ainda sobre o crime de furto, observa-se que os demais elementos circunstanciais também se mostram insuficientes para a conclusão sobre a autoria delitiva. O modus operandi semelhante a outros crimes praticados nas cidades próximas e o laudo de confronto balístico não são suficientes para a conclusão de que todos os réus praticaram os crimes, sobretudo em razão da ausência de outros elementos aptos a individualizar a conduta de cada um dos réus.

Conclusão em contrário necessariamente reclama a admissão da responsabilidade penal objetiva. Nesse sentido, veja-se precedente semelhante:

"APELAÇÕES - Artigos 33, caput e 35 da Lei nº 11.343/2006. 1. O vínculo associativo que une os membros de uma associação para o tráfico de drogas não é suficiente para torná-los igualmente responsáveis por todos os crimes de tráfico que o bando eventualmente praticar - Análise da participação de cada réu em cada um dos crimes que lhe foi imputado - Necessidade - Vedação da responsabilidade penal objetiva. 2. Associação para o tráfico ilícito de drogas - Autoria e Materialidade comprovadas - Palavra dos policiais civis - Validade - Precedentes - Fotografias extraídas durante a investigação policial dando conta da associação estável e permanente entre os acusados - Condenações mantidas - Penas - Dosimetria - Reprimenda do corréu Ricardo que deve ser majorada ante os maus antecedentes por ele ostentados. 3. Tráfico ilícito de drogas - Autoria comprovada em relação aos corréus Carlindo e Ricardo - Palavra dos policiais civis e fotografias dando conta da prática do tráfico pelos acusados - Penas - Dosimetria - Majoração da pena do corréu Ricardo, face aos maus antecedentes - Réus Matheus e Wesley - Inexistência de provas de que os acusados tenham concorrido para o tráfico de drogas - O Direito Penal não opera em conjecturas, devendo-se privilegiar o princípio do in dubio pro reu - Absolvição por falta de provas - Necessidade. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO, RECURSOS DAS DEFESAS DOS CORRÉUS CARLINDO E RICARDO NÃO PROVIDOS. RECURSO DA DEFESA DOS CORRÉUS MATHEUS E WESLEY PARCIALMENTE PROVIDO". (TJSP; Apelação Criminal 1522653-68.2020.8.26.0050; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 19ª Vara Criminal; Data do

Julgamento: 27/01/2022; Data de Registro: 03/02/2022)

De igual forma, a ausência de provas que possibilitem a caracterização da autoria delitiva de cada um dos réus considerados isoladamente obsta também o reconhecimento da autoria de um ou de alguns dos acusados. Em outras palavras: não há prova de que todos os réus estiveram nesta cidade no dia dos fatos e, mais ainda, qual foi minimamente a conduta adotada por cada um deles na empreitada criminosa.

Trata-se de mera presunção, cogitação, suspeita, afirmar que todos agiram da mesma forma como ocorreu em outras cidades.

Disso decorre, aliás, que os argumentos trazidos pelo titular da ação penal em alegações finais para demonstração de contradições defensivas (fls. 916/942 dos autos 697-34.2013 e fls. 784/792 dos autos 750-73.2017), não podem conduzir, por si só, à procedência da ação penal como requerido.

Neste sentido, como bem aponta a doutrina:

"Quem alega qualquer coisa contra alguém é que deve provar que o que está dizendo corresponde ao real. Quem é acusado, nada tem de provar. A quem é acusado cabe apenas se defender, se quiser. Assim, obviamente, não é o réu quem tem de provar que não cometeu o crime que lhe é atribuído, não é o réu quem tem de provar que a acusação não é verdadeira, não é o réu quem tem de provar que é inocente. Sua inocência, como visto, é presumida, como o é a inocência de qualquer indivíduo." (KARAM, Maria Lúcia. Liberdade, presunção de inocência e direito à defesa, Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, p.13).

Necessário destacar que os fatos relatados no interrogatório do réu Leandro Paula da Silva dizem mais respeito ao crime de furto praticado no município de Campina do Monte Alegre do que aos crimes narrados na inicial. É dos autos que o falecimento de Lucas, filho do acusado Leandro, ocorreu no dia 30/11/2013 (fls. 216, dos autos 750-73.2017), mesma data em que "criminosos explodiram caixas eletrônicas da cidade de Campina do Monte Alegre/SP, B.O. 226/2013" (conforme se anotou no relatório de investigação às fls. 179).

E, por essas mesmas razões - isto é, notadamente por não ser possível reconhecer a autoria delitiva de nenhum dos acusados -, é que a absolvição dos acusados pelos crimes de disparo de arma de fogo e de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito também se impõe. Finalizada a instrução, não restou comprovado nos autos que todos os acusados portavam arma de fogo e que todos eles tivessem efetuados disparos conforme descrito na denúncia. E, tal como em relação ao crime de furto, o reconhecimento da prática delitiva não seria possível sem que se admitisse a responsabilidade penal objetiva.

Em suma, os elementos trazidos aos autos, sem dúvida, traduzem-se em sérios indícios de que os réus praticaram os crimes descritos na inicial, mas não autorizam, em juízo de certeza, o reconhecimento da autoria delitiva. Nesse cenário, portanto, impõe-se a absolvição dos acusados pelo princípio do in dubio pro reo, mesmo porque, como acima destacado, não foram produzidas provas sob o crivo do contraditório capazes de demonstrar que os réus praticaram os crimes a eles imputados.

A propósito:

"A aplicação da máxima in dubio pro reo é decorrência lógica dos princípios da reserva legal e da presunção de não culpabilidade e, como tal, exige juízo de certeza para a prolação do juízo condenatório, sendo que qualquer dúvida acerca da materialidade e autoria delitivas resolvem-se a favor do acusado" (STJ Ministro Marco Aurélio Bellizze 5ª Turma AgRg no AREsp n 63199/MG DJe 03/09/2013).

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (ARTIGOS 33 e 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL) ABSOLVIDOS - RECURSO DO REPRESENTANTE DO "PARQUET" - Condenação IMPOSSIBILIDADE - Manutenção da absolvição dos recorridos Meros indícios de autoria e dificuldade na imputação das condutas de forma segura - CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL - PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE - Observando-se os princípios da não culpabilidade e da presunção de inocência, não cabe ao acusado

fazer prova da sua inocência, pelo contrário, compete à Acusação comprovar concludentemente a existência do fato ensejador da aplicação de pena, porque é

precisamente a certeza conquistada do delito que legitima a condenação. Em caso de dúvida, a absolvição se impõe. Recurso improvido". (TJSP; Apelação 0000086-59.2014.8.26.0590; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Vicente - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/01/2019; Data de Registro: 05/02/2019).

Por fim, oportuna a ressalva de que a absolvição dos réus tem por fundamento único e exclusivo a insuficiência de provas em relação à autoria, por exclusão de qualquer outro, de modo que incide no caso a hipótese prevista no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão estatal deduzida na denúncia para absolver os réus MARCELO NASCIMENTO da SILVA, EFERSON JOSÉ SEVERINO da SILVA, EMERSON MESSIAS SEVERINO da SILVA, FÁBIO CRUZ de ARAÚJO, JOSUÉ LUÍS FERREIRA, RÔMULO JACQUES FRANCO e LEANDRO PAULA DA SILVA do crime previsto nos artigos 155 §§ 1º e 4º, inciso IV, e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal e artigos 15, caput e 16, caput, ambos da Lei n. 10.826/03, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se certidão de honorários ao advogado dativo nomeado para defesa dos interesses dos réus, na forma do Convênio DPE/OAB (fls. 438, dos autos 697-34.2013).

Custas ex lege.

Oportunamente, efetuadas as comunicações e anotações necessárias, arquivem-se.

P.I.C.

Buri, 21 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA